

1501555-07.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501555-07.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501555-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017501/2022 - 05º D.P. ACLIMACAO, 22540760 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 2017501 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ISMAEL ALVES PEREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

GILVAN LEAL PORTO PEREIRA e ISMAEL ALVES PEREIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput e artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 14h18min, na Avenida Salim Farah Maluf, com a Rua Santa Lucia, nesta Comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, mantinham sob sua guarda e transportavam, para fins de comércio, 50 (cinquenta) tijolos de "COCAÍNA", com peso líquido de 50 quilogramas, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus foram presos em flagrante delito e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, conforme decisão proferida pelo Juízo de plantão (fls.92/96).

Os réus apresentaram defesa preliminar em fls. 173/185 (Gilvan), sendo seu pedido de liberdade provisória indeferido em fls. 198 e fls. 200/205 (réu Ismael). A denúncia foi recebida aos 14 de março de 2022 (fls.213/214), ocasião em que foi indeferido o pedido de liberdade do acusado Ismael. O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 243/245 dos autos. Os réus foram devidamente citados em fls. 251/252. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogado ao final. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público e a Defesa postularam a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, o que foi deferido. Na mesma ocasião foram indeferidos os pedidos de liberdade provisória formulados pelos réus (fls. 254/256). Em fls. 273/274 foi requerida a revogação da prisão cautelar dos réus, pedido que restou indeferido em fls. 275. O laudo pericial dos aparelhos celulares foi juntado em fls. 280/291, determinando-se a complementação da diligência em fls. 300. A prisão preventiva dos réus foi reavaliada e mantida em fls. 310, com reiteração em fls. 325. Determinou-se a quebra do sigilo telefônico relativa aos celulares apreendidos (fls. 355), com relatórios indicados no link juntado em fls. 363. Em alegações finais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, condenando-se os réus nos termos da denúncia, bem como o reconhecimento da causa de aumento art. 40, V, impondo-se regime fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 367/377). A Defesa do réu Gilvan apresentou memoriais em fls. 378/386, requerendo a improcedência da denúncia, com sua absolvição por ausência de provas, notadamente por não terem sido localizados entorpecentes em poder dele. Aduziu que sequer conhecia o corréu anteriormente aos fatos, não tendo sido arroladas testemunhas alheias aos quadros policiais. A Defesa do réu Ismael, por seu turno, apresentou memoriais em fls. 387/390, postulando a parcial procedência da ação penal. Argumentou que o réu não tinha ciência sobre o transporte de entorpecentes, embora soubesse da ilicitude dos produtos. Postulou a aplicação da atenuante da confissão, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando não pertencer a organização criminosa.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A hipótese é de parcial procedência da ação penal, condenando-se o réu Ismael e absolvendo-se o réu Gilvan, por insuficiência probatória. A materialidade do crime restou evidenciada pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 56/58, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 243/245, prova técnica que atestou ser cocaína a substância apreendida no veículo conduzido pelo réu Ismael. A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo, no que tange ao réu Ismael. A testemunha Alex Júnior Amarilho do Nascimento Silva, policial civil, disse que haviam recebido informação sobre um veículo Montana 9403, que viria pela av. Salim Farah Maluf, escoltando um ônibus ou caminhão com drogas no compartimento. A denúncia foi feita pessoalmente, ao próprio depoente, acredita que tenha sido transformada em ordem de serviço, mas não se recorda ao certo. Em diligências ao local, após cerca de duas horas de espera na região da av. Salim Farah Maluf, visualizaram o veículo Montana e o ônibus. Inicialmente a abordagem foi feita no ônibus, o motorista negou a existência de qualquer ilícito, mas posteriormente acabou admitindo que transportava drogas. Retomaram a busca ao veículo Montana, que acabou por ser abordado no pedágio da Rodovia Fernão Dias. O motorista acabou por admitir que estava atuando como "batedor" do ônibus. Havia 50 tijolos de cocaína, de 1 kg cada um, que foram encontrados escondidos embaixo do assoalho, sob os bancos do ônibus, foi necessário desparafusar o assoalho e procurar bastante, não

houve informação espontânea a respeito. O motorista do ônibus estava com a quantia de R\$ 5.000,00, que disse ter recebido para fazer o transporte das drogas, ao passo que o da Montana receberia R\$ 10.000,00. Não havia nada de ilícito com o réu Gilvan, que dirigia a Montana. Ele não resistiu à abordagem, mas também não pareceu surpreso com a prisão. O réu Gilvan sabia que havia drogas no ônibus, tanto assim que posteriormente acabou informando que as drogas estavam próximas da escada do ônibus. Não conhecia os réus anteriormente. Nada mais de ilícito foi encontrado com os réus.

A testemunha Cláudio Severino Boscolo, policial civil, corroborou o relato do colega. Disse que viram o veículo Montana passar, seguido por um ônibus. Este foi inicialmente abordado, relatou que levaria cestas básicas e água até o nordeste. Confrontado com a informação do depoente sobre os entorpecentes, o motorista do ônibus acabou admitindo que faria o transporte dos entorpecentes. Foram encontrados R\$ 5.000,00 na carteira do motorista do ônibus, os quais ele admitiu tratar-se do pagamento pelo transporte das drogas. O policial Alex foi ao encalço do veículo Montana, acompanhado de outros colegas da delegacia, logrando localizá-lo próximo ao pedágio. O depoente não entrevistou o motorista da Montana, as informações que tem a respeito foram passadas pelo colega Alex. O réu que está de óculos no dia de hoje era o motorista do caminhão. Não levantou a documentação dos veículos, Nada de ilícito foi encontrado em poder dos réus. Não parecia que os réu se conheciam, não os viu conversando.

Ao ser interrogado, o réu Ismael disse que estava almoçando em sua carreta, dois dias antes dos fatos, quando um outro motorista se aproximou e ofereceu um serviço, consistente no transporte de uma carreta até Feira de Santana-BA, a pedido de seu patrão. Esse motorista disse que seu patrão pagaria R\$ 5.000,00 pelo serviço, o réu aceitou. Encontrou o motorista e o patrão em um posto de gasolina na região da zona leste. Ali o patrão informou que a carreta não ficara pronta, e que ele levaria um ônibus no qual havia cestas básicas e donativos para a região da Bahia, que havia sido atingida pelas chuvas. O patrão lhe deu mais mil reais e explicou que era em razão de haver também cigarros paraguaios no ônibus. Um dos policiais ameaçou o réu e o pressionou para que falasse onde estavam os entorpecentes. Não conhecia o corréu anteriormente. Não sabe o nome completo da pessoa que o contratou para fazer o transporte do ônibus, ele se apresentou apenas com João. Nunca foi preso ou processado antes. Não estranhou a oferta de R\$ 5.000,00 para levar a carreta, pois ainda teriam que ser abatidos desse valor as despesas com combustível, óleo e pedágio. Não desconfiou de modo algum que pudesse haver algo errado com esse transporte. Olhou a documentação do ônibus antes de sair. Disse que não conferiu as notas fiscais das mercadorias. Quando soube sobre o cigarro, apenas aceitou fazer o transporte porque o sr. João disse que seria pouca quantidade. Não tinha o telefone desse senhor, conversou com ele apenas pessoalmente. Não estava com dois celulares no momento da prisão, estava apenas com um. O rapaz que inicialmente o abordou e ofereceu o serviço de transporte se chamava Jean, falou com ele apenas uma vez por whatsapp. Reafirma que nunca tinha visto Gilvan antes.

O réu Gilvan, por seu turno, disse que trabalhava como mecânico. Comprou uma Montana, cuja placa não se lembra, e rumou a Fernão Dias, para visitar um primo na cidade de Três Corações. Foi abordado pelos policiais logo após o pedágio, de forma muito truculenta. Os policiais o colocaram na viatura e o levaram até um posto onde estava Ismael, a quem não conhecia antes. Foi levado à delegacia, lá os policiais passaram a ameaçá-lo, ficou sem comer por dois dias. Não entendeu o que aconteceu, disseram que ele era de facção. Não sabe porque está sendo acusado, nunca tinha visto os policiais antes. Não falou no IML sobre as agressões porque teve medo de sofrer represálias. Nunca foi preso ou processado criminalmente, ganhava cerca de R\$ 5.000,00 por mês. Completou o primeiro grau. Comprou o veículo Montana de uma cliente chamada Maria, a qual adquirira o veículo em leilão. O carro estava com muitos problemas de motor, funilaria e pintura. O contrato com a senhora Maria foi verbal, não tem outros dados para localização dela. Iria pagar o carro quando a senhora Maria fosse até a oficina cobrar. O parente que visitaria na cidade de Três Corações se chama Fernando. O réu avisou ao referido parente que iria fazer uma visita. Não sabe de cor o telefone de Fernando, acredita que sua esposa saiba. Não

sabe o número do seu celular. No dia em que foi preso estava com dois celulares, pois usa um deles apenas para passar aos clientes. Os dois celulares foram apreendidos. Sacou a quantia de R\$ 100,00 do Santander, para fazer a viagem. Os policiais jogaram álcool no seu corpo, Ismael não estava junto com o interrogando, pois nessa hora ele fora retirado de cela. Acredita que Ismael tenha ouvido os policiais o ameaçarem. Não sabe se Ismael também foi agredido. Como visto, as versões dos réus encontram respaldo na prova dos autos, ainda que parcialmente.

Com efeito, esclareceram os policiais civis que seguiram até o local dos fatos a fim de localizar um veículo GM/Montana, após receberem denúncia anônima de que tal veículo estaria escoltando um ônibus de turismo contendo entorpecentes. Chegando ao local, visualizaram ambos os veículos, mas conseguiram abordar apenas o ônibus, inicialmente, sendo o réu Gilvan abordado em outro local, na condução do veículo GM/Montana. Nada de ilícito foi encontrado com Gilvan, mas ele teria admitido a alocação das drogas em um compartimento secreto no ônibus. O réu Ismael conduzia o ônibus e ao ser abordado, confessou que tinha a intenção de transportar os entorpecentes até o Nordeste do País. Os policiais confirmaram, ainda, que localizaram o compartimento secreto, bem como os cinquenta tijolos de cocaína, além da quantia em dinheiro com o réu Ismael.

Assim, a prova produzida pela acusação autoriza a condenação do acusado Ismael pelo crime de tráfico, na medida em que absolutamente firmes os depoimentos no sentido de que foi encontrada a droga na posse do denunciado, com a finalidade de transporte para outro Estado. Destaque-se que o transporte da carga ilícita foi admitido pelo próprio réu Ismael, ainda que aduzindo não saber tratar-se de substâncias entorpecentes, o que não convence.

Saliente-se, ainda, que diante das condições em que encontradas as drogas, especialmente da elevadíssima quantidade e notadamente da forma como acondicionadas, vale dizer, em tijolos, escondidos sob compartimento secreto, indubitável que serviriam à entrega e ao consumo de terceiros.

Nesta medida, ainda que os acusados não tenham sido flagrados durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, na tradição, deve ser condenado nos termos da imputação inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Restou comprovada nos autos, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei, pois demonstrado durante a instrução que o objetivo do réu Ismael era transportar as substâncias para Feira de Santana, na Bahia, em troca de pagamento. Tal intuito foi cabalmente revelado pela confissão do réu e pelo elevado montante por ele recebido para realização do serviço, justificado pela longa distância a ser percorrida.

De outro lado, no que tange ao acusado Gilvan, diversa é a solução. Isso porque, analisando detidamente a prova colacionada sob o crivo do contraditório, vê-se que os firmes indícios de autoria existentes quando do recebimento da denúncia não se convolveram na prova robusta e inequívoca imprescindível à condenação penal. Não se trata de desconsiderar a possibilidade de fundar-se a condenação penal em depoimentos de policiais, pois eles não são impedidos de depor e tampouco podem ter questionada a credibilidade de seus relatos exclusivamente por sua condição funcional.

No entanto, para embasarem a convicção do julgador quanto à autoria delitiva, os depoimentos devem vir amparados por outros elementos, de modo que se forme conjunto probatório consistente. Contudo, não foi o que se verificou no presente feito. Na hipótese, não foram encontrados com o réu Gilvan quaisquer objetos ilícitos, sequer tendo sido ele abordado no mesmo local em que o réu Ismael. Conquanto os policiais tenham informado que sua função de "batedor de pista" fora confirmada pelo próprio réu Gilvan, não foram amealhados outros elementos indicativos dessa

condição, restando a assertiva isolada nos autos. Os entorpecentes não estavam em poder do réu Gilvan ou em seu veículo, sendo certo que a denúncia anônima referida pelos policiais sequer foi anexada ao inquérito policial.

Ademais, as perícias realizadas nos aparelhos celulares dos réus Gilvan e Ismael não apontaram troca de mensagens ou comunicação entre eles, o que indicaria o trabalho conjunto para transporte das drogas indicado na denúncia. Tampouco restou comprovado nos autos que os réus se conhecessem anteriormente, tendo sido a abordagem de ambos efetuada em locais distintos e distantes.

Portanto, diante das fragilidades no panorama probatório acima apontadas quanto à participação do réu Gilvan no transporte de entorpecentes, e considerado a consagração do princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, em que a dúvida deve militar em favor do acusado, não há outra alternativa possível nestes autos diversa da absolvição em relação a ele. Frise-se que no caso em tela imputa-se crime de alta gravidade ao réu, cujas sanções requerem a certeza motivada do julgador, certeza essa que não pode decorrer de simples denúncia anônima e confissão informal do réu.

Neste sentido:

'Indícios de autoria e materialidade – fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo – valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' - RT 834/686.

Ademais, segundo orientação pretoriana, “entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o “non liquet” e absolver o réu” (RJTACRIM 40/216).

À vista do exposto, evidenciada a insuficiência probatória quanto ao réu Gilvan, impõe-se sua absolvição. Comprovada, contudo, a ocorrência de delito de tráfico de drogas praticado pelo réu Ismael, imperiosa sua condenação, pelo que passo à dosimetria da pena.

Não havendo elementos desabonadores da conduta do réu, fixo a pena base no mínimo legal cominado ao tipo penal, a saber, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo. Destaco que a elevadíssima quantidade de entorpecentes será considerada apenas na terceira fase da dosimetria penal, afastando-se alegações de *bis in idem*.

Na segunda fase da dosimetria, a despeito da parcial confissão do réu, descabida redução aquém do mínimo legal nesta etapa da dosagem da reprimenda.

Na terceira fase da dosimetria penal, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, pelo que elevo a pena em 1/6, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, a despeito do esforço argumentativo ministerial, reputo inviável o afastamento do redutor de pena previsto na lei especial. Embora a quantidade de drogas por ele transportada seja elevadíssima, tal fato, isoladamente, não pode obstar a aplicação do redutor, nos termos do entendimento majoritário dos tribunais superiores. Na hipótese, o réu é primário e de bons antecedentes, não tendo sido amealhados aos autos outros elementos comprobatórios de que já esteja imerso em atividade estruturada do comércio de drogas. Daí porque o fato de estar transportando quantidade elevada de drogas, isoladamente, não afasta a possibilidade de que seja iniciante na traficância, fazendo jus ao privilégio legal.

Para modulação da fração de redução, contudo, viável o embasamento na quantidade de entorpecentes, pelo que, no caso em tela justifica-se a redução mínima, no montante de 1/6, considerando o total de 50 kg de cocaína apreendido. Totalizando a pena final, portanto, em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Nesse sentido é o recente julgado: “É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último

caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena." (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, reconhecido o delito em sua forma privilegiada, cabível o regime semiaberto, considerando o montante da pena e o intenso desvalor da conduta do réu. Pelo mesmo motivo, descabidas substituições ou outras benesses legais.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu ISMAEL ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um deles no mínimo legal, por não haver razões comprovadas nos autos para sua exacerbação, bem como para ABSOLVER o réu GILVAN LEAL PORTO PEREIRA da acusação que lhe é feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em consequência, revogo a prisão preventiva do réu GILVAN. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Quanto ao réu ISMAEL, a despeito da condenação em regime intermediário, tratando-se de réu primário e delito cometido sem violência ou grave ameaça, hei por bem conceder-lhe o direito ao recurso em liberdade, homenagem ao princípio da presunção de inocência. Anoto que não mais se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, resguardada que se encontra a instrução penal, ora encerrada, pelo que revogo sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei. Declaro o perdimento da quantia apreendida com o réu ISMAEL.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada ao réu ISMAEL.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA